

1500591-85.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... 16 gramas de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto, o acusado Helder foi surpreendido com 51 porções ou 18,8 gramas de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda na mesma ocasião, o acusado Matheus vendia e mantinha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500591-85.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500591-85.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2143455/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5278957 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11302/19/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2143455 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11302/19/404

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2143455 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,

11302/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

LUCAS GABRIEL DE SOUSA FRANCISCO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Helder Saraiva Mariano da Silva, Lucas Gabriel de Souza Francisco e Matheus de Araújo Lima, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado Lucas, no dia 15 de maio de 2019, às 19h30, na Rua Landerico Micheletti, 2-53, Núcleo Habitacional José Regino, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 53 eppendorfs ou 16 gramas de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo contexto, o acusado Helder foi surpreendido com 51 porções ou 18,8 gramas de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda na mesma ocasião, o acusado Matheus vendia e mantinha em depósito entorpecente, em sua casa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22), laudo de constatação preliminar (fls. 23/26) e laudo definitivo (fls. 375/378).

Pelo crime, foram os acusados Helder e Lucas presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 51/55), foi concedida a liberdade provisória aos acusados, com a imposição de medidas cautelares.

Pela decisão de fls. 146, foram determinadas a notificação e a citação dos acusados.

Os réus foram, formalmente, citados (fls. 160), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 201/208, 236 e 315).

Na decisão de fls. 216/218, houve o recebimento da denúncia no tocante aos acusados Helder Saraiva Mariano e Matheus de Araújo Lima.

Na decisão de fls. 243/247, foi decretada a prisão preventiva do acusado Lucas Gabriel de Souza Francisco, em razão do descumprimento das cautelares, mesmo ocasião em que foi determinada a suspensão do processo nos moldes do art. 366 do CPP.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 313/317 foi revogada a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do acusado Lucas, sendo determinada a expedição de contramandado de prisão. Na mesma ocasião, as partes desistiram das oitivas das testemunhas Natalie, Paulo e Gilberto, pleitos homologados. Durante o mencionado ato processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os acusados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 330/338 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a constatação da personalidade transviada no tocante ao acusado Helder, a valoração da agravante do "estado pandêmico" e o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, em razão da prática de atividade criminosa, com a fixação do regime inicial fechado para todos os acusados.

Já a D. Defesa constituída do acusado Matheus às fls. 342/357 pleiteou, em síntese, a absolvição por falha no arcabouço probatório ou a aplicação da minorante do "tráfico-privilegiado", com a possibilidade de recurso em liberdade e a concessão da gratuidade judiciária.

A Defensoria Pública às fls. 363/374 representando os interesses dos acusados Helder e Lucas, buscou, em suma, a absolvição por ausência de provas, ou a constatação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, pela presença dos requisitos legais, bem como o afastamento da agravante do "estado pandêmico".

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22), laudo de constatação preliminar (fls. 23/26) e, em especial, pelo laudo definitivo (fls. 375/378).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Daniel Souza e Daiana, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em síntese, que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio de drogas. Afirmaram que, em frente à residência mencionada nos autos, foi avistado um veículo vermelho, bem como notaram que uma pessoa (acusado Lucas) saiu da residência e entrou no citado automóvel. Informaram que ele carregava algo nas mãos e, por tal razão, resolveram acompanhá-lo e deram ordem de parada, mas ele não obedeceu. Esclareceram que, durante o trajeto, Lucas saiu do automóvel e se evadiu do veículo, embrenhando-se no mato, bem como dispensando alguns eppendorfs de cocaína, contudo, ele foi detido. Mencionaram que ele contou que havia ido, com o corréu Helder, até a casa de Matheus, para pegar

entorpecentes. Citaram que outra equipe da polícia ficou na residência. Asseveraram que uma pessoa, assim que percebeu a presença dos policiais, correu para dentro do imóvel e, por isso, decidiram adentrar no imóvel. Disseram que, no local, estavam o acusado Helder, além de Paulo e Natalie. Afirmaram que, em um dos quartos daquele imóvel, encontraram mais eppendorfs de cocaína. Informaram que, inicialmente, Natalie e Paulo disseram que não sabiam a quem pertencia os entorpecentes, contudo, na delegacia, eles confirmaram que as drogas encontradas eram dos acusados Helder e Matheus. Esclareceram que eles separavam as drogas naquele quarto. Mencionaram que, durante as buscas, foram procurados por vizinhos, reportando que uma pessoa teria fugido, quebrando telhas das casas vizinhas. Citaram que um dos abordados contou que tal pessoa que teria fugido era o acusado Mateus. Asseveraram que o motorista do automóvel vermelho era motorista de Uber e contou que foi até aquela residência buscar droga. Disseram que o acusado Lucas confirmou que havia ido até a casa de Mateus buscar droga para abastecer um 'ponto de droga' da Avenida Norte.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha Vanderci Pereira, em juízo (mídia SAJ), disse, em síntese, que era motorista do aplicativo 99. Afirmou que foi chamado para uma corrida. Informou que, durante o trajeto, notou um sinal de luz da viatura. Esclareceu que o passageiro abriu a porta e saiu correndo e não soube 'se ele foi pego pela polícia'.

A testemunha de defesa Renata Gois, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em suma, que o acusado Matheus, no dia dos fatos, estava na casa de sua irmã.

O acusado Helder, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que foi até a residência de Isac, levar ração. Afirmou que, neste instante, a polícia invadiu o local e passou a perguntar sobre Matheus. Informou que nenhuma droga foi apresentada na hora, mas somente na delegacia.

O acusado Lucas, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em síntese, que foi até a residência de Matheus, para conversarem. Afirmou que pediu para Isac, irmão de Matheus, chamar um Uber. Informou que, durante o trajeto, a polícia os abordou. Esclareceu que abriu a porta do carro e saiu correndo, entretanto, acabou detido pelos policiais. Mencionou que correu porque 'pensou que seria preso por conta de seu processo de violência doméstica'. Citou que foi com a polícia até a casa de Isac, onde Helder estava algemado. Asseverou que os policiais apresentaram drogas, as quais desconhece a origem.

O acusado Matheus sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em resumo, que não estava no local e somente soube dos fatos posteriormente. Afirmou que é amigo dos demais réus.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

De acordo com a prova amealhada, em patrulhamento rotineiro, os policiais avistaram o acusado Lucas, saindo correndo de um veículo de aplicativo, tendo dispensado ependorfs de cocaína.

Ele foi detido enquanto outra equipe de policiais permaneceu em frente à casa de onde Lucas tinha saído.

Na fase policial, o motorista de aplicativo Vanderci disse que notou que o acusado Lucas estava com os 'braços cruzados na frente da barriga', aparentando 'estar com frio' (fls. 09).

Tal atitude, seguramente, visava que o entorpecente permanecesse ocultado, até porque não há substrato para o acusado Lucas ter corrido em razão de eventual feito de violência doméstica.

No imóvel, ao verem os policiais, uma das pessoas apresentou comportamento suspeito e, com entrada dos policiais no imóvel, foi encontrada mais droga (da mesma natureza e com similar forma de acondicionamento, em um quarto).

Durante a seara inquisitiva (fls. 11), na presença do Douto Patrono, a testemunha Natalie mencionou que Helder estava na casa, na qual reside Matheus (seu cunhado).

Além disso, citou que o quarto no qual a droga foi apreendida era utilizado por Helder e Mateus, para o delito de traficância, em razão da luminosidade.

Já a testemunha Paulo Gustavo, irmão de Matheus, e residente no local da apreensão, citou que Helder e Lucas também estiverem no local. Ele ainda declinou que Matheus saiu do local, sem precisar por onde, além de delinear que a droga estava com Helder (fls. 12).

O próprio acusado Matheus, durante o interrogatório judicial, disse que 'todos eram amigos'.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Réu Helder Saraiva Mariano da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

Com efeito, o acusado foi condenado por outro crime de tráfico - feito nº 1500995-39.2019.8.26.0594, fls. 280/280 - o qual não pode ser utilizado em seu desfavor, sob pena de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS . RECEPÇÃO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA.

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR AO ILÍCITO PRATICADO.

IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

INVIABILIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, seja para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes. 2. Desatendidos os requisitos subjetivos, inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Ordem concedida em parte, apenas para reduzir a pena do paciente.

(STJ, 6ª Turma, HC nº 168.621-SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/06/2012)

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico", deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a r. jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)
Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.
Com efeito, como dito, o acusado cometeu novo delito após os fatos.
E tal circunstância é apta para afastar a benesse.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 553258 / MG, relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 23/06/2020)

Por isso, a pena atingida na primeira fase é a definitiva.

Réu Lucas Gabriel de Souza Francisco

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, conforme fundamentação já lançada.

Na segunda fase, inaplicável a agravante “estado pandêmico” pelos motivos expostos.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, como dito, o acusado possui anotação na seara infracional (fls. 49), inclusive pela mesma prática delituosa.

E tal circunstância é apta para afastar a benesse.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 447045 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/08/2018).

Por isso, a pena atingida na primeira fase é a definitiva.

Réu Matheus de Araujo Lima

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, conforme fundamentação já lançada.

Na segunda fase, inaplicável a agravante "estado pandêmico" pelos motivos expostos.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é responsabilizado por delito de tráfico diverso (feito nº 1512218-40.2018, fls. 278/279), cometido pouco antes dos fatos aqui tratados.

E tal circunstância é apta para afastar a benesse.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENHIDA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV Ação penal em andamento. Possibilidade de utilização para afastar o tráfico privilegiado. Não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, entendendo evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto processo que apura a prática de furto pelo paciente - que indica sua dedicação à atividade criminosa. Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017.

(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 674560 / SP, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 14/09/2021)

Por isso, a pena atingida na primeira fase é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado, eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam, preventiva e repressiva.

Os acusados, de algum modo, como mencionado, permaneceram no mundo do crime.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO os réus HELDER SARAIVA MARIANO DA SILVA, LUCAS GABRIEL DE SOUZA FRANCISCO e MATHEUS DE ARAUJO LIMA, qualificados nos autos, cada qual, a cumprir, a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentas) diárias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Os acusados permaneceram soltos durante o trâmite processual, e, agora, não revelados os pressupostos, fundamentos e requisitos para a custódia cautelar, especialmente a necessária contemporaneidade, de modo que será possível eventuais recursos em liberdade.

Quanto aos eppendorfs e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA